

1501963-67.2022.8.26.0302

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Virginia Mendes Veloso Cardoso

Comarca: Jaú

Foro: Foro de Jaú

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/11/2022

... Estatuto do Desarmamento. Sanções do tráfico intocadas. Regimes preservados. PROVIMENTO PARCIAL. Classe/Assunto: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins. Relator(a): Eduardo Abdalla. Comarca: Tatuí. Órgão julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal. Data de publicação: 05/11/2020.

No mérito, a ação é parcialmente procedente.

A materialidade do crime de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaú

Foro de Jaú

2ª Vara Criminal

Praça Dr. Mário Gomes Pahin, s/n, Jaú-SP - cep 17210-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501963-67.2022.8.26.0302

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2144234/2022 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 25218803 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2144234 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

CARLOS PEREIRA DOS SANTOS e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Virginia Mendes Veloso Cardoso

VISTOS.

EDUARDO DOS SANTOS CONCEIÇÃO SOUZA, vulgo "Arroz", e CARLOS PEREIRA DOS SANTOS, vulgo "Cal", estão sendo processados como incursos no artigo 33, "caput", e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, combinados com os artigos 29 (concurso de pessoas) e 69 (concurso material), ambos do Código Penal.

Notificados (fls. 358 e 360), os réus apresentaram resposta à acusação às fls. 352/354 (Carlos) e 419/420 (Eduardo).

A denúncia foi recebida em 26 de agosto de 2022 (fls. 421) e os réus foram citados (444 e 447).

Durante a instrução, foram ouvidas testemunhas e os acusados foram interrogados (fls. 492).

Em memoriais de alegações finais, o representante do Ministério Público requereu a procedência da ação penal, nos termos da denúncia (fls. 500/505).

As defesas de Carlos e de Eduardo arguíram a nulidade da diligência de busca e apreensão, pleitearam a absolvição e, subsidiariamente, a desclassificação dos delitos para a conduta prevista no artigo 28, da Lei 11.343/06 (fls. 508/514 e fls. 515/566). Em acréscimo, a defesa de Eduardo requereu a aplicação da causa de diminuição do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 e demais benesses legais.

É O RELATÓRIO.
DECIDO.

Inicialmente, não merece guarida a arguição defensiva de nulidade processual.

Não há vedação legal ou constitucional à notícia anônima de crime. Como bem se sabe, o Poder Público incentiva a população a que informe às autoridades sobre fatos criminosos de que tenham conhecimento, visando, assim, dar mais efetividade à prevenção e à repressão às práticas ilícitas. Nessas situações, a pessoa não é compelida a se identificar, o que estimula a participação da comunidade no combate aos crimes. Portanto, seria um contrassenso estimular a sociedade a denunciar uma atividade delituosa para, depois, infirmar esse elemento de convicção e considerar contaminadas todas as provas subsequentes, ainda que produzidas lícitamente a partir daquela.

E, por óbvio, não foi a simples denúncia que acarretou a prisão dos réus. Elas deram início às investigações preliminares empreendidas pelos policiais civis e azo à expedição de mandado de busca e apreensão que culminou com o encontro das drogas e apetrechos e a confirmação das informações recebidas acerca do comércio espúrio praticado pelos acusados.

Nesse sentido:

TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES (USO PERMITIDO). Recurso defensivo. PRELIMINAR. Alegação de suposta nulidade do início de investigação por “denúncia anônima” que se confunde com a questão de fundo. MÉRITO. Pretendida absolvição. Inviabilidade. Autoria e materialidade bem delineadas. Acervo probatório robusto. Condutas típicas. Prisão flagrante que se deu pela certeza visual do delito e não por delação anônima. DOSIMETRIA. Readequação do incremento operado unicamente às iniciais do delito do Estatuto do Desarmamento. Sanções do tráfico intocadas. Regimes preservados. PROVIMENTO PARCIAL. Classe/Assunto: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins. Relator(a): Eduardo Abdalla. Comarca: Tatuí. Órgão julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal. Data de publicação: 05/11/2020.

No mérito, a ação é parcialmente procedente.

A materialidade do crime de tráfico foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 7/15), boletim de ocorrência (fls. 23/26), auto de exibição e apreensão (fls. 29/30), auto de reconhecimento fotográfico (fls. 33/34), fotografias (fls. 51/52 e 86/90), laudos periciais (fls. 263/269, 270/274 e 275/289), além da prova oral.

O réu Eduardo negou o delito. Relatou que estava usando cocaína com Carlos e que havia subido no telhado para trocar uma telha quando os policiais chegaram. Usava a balança apreendida para conferir o peso das drogas que adquiria para consumo. Tinha vendido seu veículo para quitar uma dívida de R\$6.000,00. Estava sendo ajudado por

familiares na época dos fatos, pois estava usando muita droga. Fugiu e foi abordado na sequência pelos policiais. Carlos trabalhava com recicláveis e havia aberto um bar nos dias que antecederam a prisão.

O réu Carlos rechaçou a acusação e contou que Eduardo o chamou para usar cocaína na casa dele. Quando os policiais chegaram, subiu no telhado, pulou no quintal da vizinha e lá permaneceu, pois tem medo de polícia quando está drogado. Costumavam usar drogas juntos em festas e dividiam tais substâncias. Não tem nada contra os policiais ouvidos. Há 30 anos residia no mesmo endereço. Possui um pequeno comércio e arrecada materiais recicláveis. Não chegou a ver apetrechos na casa de Eduardo, sabe que o local era uma espécie de “fumódromo” e não tem conhecimento de que fosse uma “biqueira”.

Bethlyn, esposa do réu Eduardo, disse que estava em sua casa quando os policiais chegaram e os réus fugiram. Não sabe o que os acusados estavam fazendo, mas acredita que estivessem usando drogas. Fazia apenas três dias que havia voltado de Aracaju/SE e não estava inteirada sobre o que estava acontecendo. Soube por terceiros que os réus faziam uso de drogas, mas não comercializavam. Os policiais arrombaram o imóvel para entrar. Soube que Eduardo havia vendido um carro para comprar entorpecentes e acredita que o dinheiro apreendido era proveniente do referido negócio. Eram auxiliados por familiares para se sustentarem.

O policial civil Bruno narrou em juízo que, durante investigações preliminares, apurou que no local dos fatos estava sendo praticado o comércio espúrio, o que foi corroborado por denúncias, e embasou o pedido de expedição de mandado de busca e apreensão. No dia do cumprimento da diligência, os réus fugiram pelos fundos da residência quando ouviram o barulho dos policiais, que conseguiram prender “Arroz”. Na residência havia drogas e dinheiro. Estavam no local a amásia de “Arroz” e mais uma mulher, que admitiu na delegacia já ter adquirido drogas de ambos os réus ou trocar, com Eduardo, entorpecentes por prestação de serviços. Não viu o que os acusados estavam fazendo quando chegou. É impossível a realização de campanhas no local, mas as informações davam conta de que os acusados se revezavam na prática do comércio ilícito, em que pese não tenha visto nenhum dos dois no local durante as investigações.

O policial civil Paulo confirmou, em linhas gerais, a dinâmica relatada pelo policial civil Bruno. Acrescentou que as denúncias davam conta de que o comércio espúrio era praticado por “Arroz” com a ajuda de “Cal”, sendo que ambos eram conhecidos nos meios policiais. O imóvel ostentava características típicas do comércio de drogas, como buraco na parede, bancada para o manuseio de entorpecentes, além da existência de apetrechos relativos ao tráfico. Havia uma usuária no local que admitiu estar ali para adquirir tais substâncias. Avistou uma mulher (a quem conhece de longa data e sabe ser usuária) indo em direção ao portão da casa, mas ela foi abordada antes de entrar. Na bolsa que Eduardo portava ao fugir havia uma quantia e sabe que Carlos também levou uma bolsa ao fugir. Durante as diligências investigativas não visualizou nenhum dos réus no local.

Pois bem. Como se vê, as provas são suficientes apenas para a segura comprovação do crime de tráfico atribuído aos réus.

É certo que, no dia dos fatos, Carlos auxiliava Eduardo no manuseio das drogas que seriam destinadas à venda, conduta corroborada pelo conjunto probatório colhido, notadamente os depoimentos dos policiais e os relatos prestados, em solo policial, pela esposa do réu Eduardo e pela usuária de drogas que estava na casa (que afirmaram que ambos manuseavam drogas quando os policiais chegaram, bem como que eles comercializavam as referidas substâncias).

Os policiais apresentaram narrativas coerentes e harmônicas acerca dos fatos que embasaram o pedido de busca na casa do réu Eduardo, bem como sobre a conduta

adotada por ambos os acusados durante a diligência e, ainda, das características indicativas de que o local era usado para o comércio ilícito. E nada há nos autos capaz de colocar em dúvida os sobreditos depoimentos, nem se vislumbra qualquer motivo para que desajassem incriminar falsamente os acusados, que afirmaram nada terem contra eles.

A propósito: Convém lembrar que os atos administrativos são dotados da presunção de veracidade e legalidade e, não havendo qualquer indício que possa macular esta qualidade, não é de se admitir, por simples contrariedade do sentenciado, que os depoimentos dos agentes públicos estejam eivados de ilegalidade, por um espírito emulativo ou qualquer outra causa espúria. Saliente-se que os depoimentos dos policiais valem como prova, inexistindo razão para desmerecê-los, pois, na condição de servidores públicos, no exercício de suas funções, gozam de presunção juris tantum de que agem corretamente, sobretudo quando suas afirmações são compatíveis com o conjunto probatório. Além disso, 'A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita' (STF, RTJ 68/54). (Apelação nº 0004050-23.2013.8.26.0161 - 4ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo - Relator Willian Campos - julgado em 27 de maio de 2014 - votação unânime).

"PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO COM BASE NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO (....) 2. O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso. (....)" (STJ, HC 165.561/AM, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 15/02/2016).

No mais, os apetrechos localizados na casa de Eduardo, tais como balança, tesoura e lâmina com resquícios de droga (fls. 263/269), são usualmente ligados à mercancia ilícita, o que, aliado ao restante do conjunto probatório, não deixa dúvidas da destinação à venda do crack, até porque, sob o crivo do contraditório, os réus alegaram estarem reunidos para usarem cocaína.

A versão do réu Eduardo de que usava a balança para pesar as drogas apenas para o próprio consumo é inverossímil, pois não se supõe que um usuário 'devolva a droga' ou retorne ao traficante fornecedor para fazer reclamações, mormente em virtude dos meios intimidatórios normalmente utilizados por tais pessoas.

Em adição, o fato dos réus não terem sido surpreendidos no exato momento da comercialização do entorpecente não afasta a incidência do artigo 33 da Lei 11.343/06, que elenca diversas condutas que se enquadram na prática delituosa prevista no tipo penal. De qualquer modo, não é demais observar que havia uma usuária no local e outra foi abordada na porta. Nesta senda:

Apelação. Tráfico de drogas. Absolvição por insuficiência de provas. Inviabilidade. Autoria e materialidade bem demonstradas. Desclassificação para o tipo previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/06. Impossibilidade. Quantidade da droga e forma de acondicionamento que evidenciam a prática da traficância. Reconhecimento do delito em sua modalidade tentada. Não cabimento. O tráfico de drogas é tipo penal misto alternativo. Possuindo 18 ações distintas, o delito se consuma com a prática de um dos núcleos do tipo penal. A conduta "trazer consigo" é delito de mera conduta, que não admite a modalidade tentada. Aplicação do redutor do §4º do artigo 33, da Lei n. 11.343/06 em sua fração máxima. Quantidade de droga apreendida que não pode ser considerada expressiva tendo em vista o local de cometimento do delito - a cidade de São Paulo. Fixação de regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos em face da quantidade de pena aplicada e da primariedade do agente. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal

0001899-83.2014.8.26.0635; Relator (a): Leme Garcia; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 18ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 01/12/2015; Data de Registro: 04/12/2015).

E, ainda que os réus sejam usuários de entorpecentes, isso não exclui a possibilidade de que os vendam, posto que tais condutas frequentemente coexistem, até mesmo para sustento do consumo. Sobre o tema, veja-se:

“TOXICO – Tráfico – Absolvição – Inadmissibilidade – Réu surpreendido com entorpecente pronto para o comércio – Prova colhida que direciona-se nesse sentido – Fato de ser usuário que pode coexistir com a traficância – Condenação mantida – Recurso não provido. (Apelação Criminal n. 287.012-3 – Ribeirão Preto – 4ª Câmara Criminal – Relator: Bittencourt Rodrigues – 22.08.00 – v.u.).”

Nesse contexto, forçoso reconhecer que as provas são suficientes para comprovação do tráfico imputado aos réus no dia dos fatos. Noutra ponta, embora haja fortes indícios do delito de associação, notadamente em virtude das investigações que precederam a expedição do mandado de busca, remanesce dúvida quanto tal vínculo.

A conduta prevista no artigo 35 da Lei de Tóxicos exige, para sua caracterização, efetivo liame entre os indivíduos, de sorte que a simples coautoria não se amolda ao que prevê o sobredito diploma legal.

Desta feita, de rigor a parcial procedência da ação para condenar os réus apenas pelo crime de tráfico de entorpecentes.

Passo, pois, a dosar as penas.

Eduardo Dos Santos Conceição Souza

Na primeira fase, atentando ao disposto no art. 42 da Lei 11.343/06, observo que a pena-base deve ser majorada, considerando a alta potencialidade lesiva do entorpecente apreendido (“crack”), substância altamente nociva e viciante. Assim, fixo a pena-base acima do mínimo legal em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Ausentes atenuantes e agravantes.

Aplicável o disposto no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, à mingua de suficiente comprovação de que o acusado se dedicasse a atividade criminosa por tempo considerável antes dos fatos ou integrasse organização criminosa. Assim, diminuo a reprimenda em 2/3, tornando-a definitiva em 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 194 dias-multa.

Considerando os motivos esposados na primeira fase, mas, por outro lado, a primariedade do réu, fixo, excepcionalmente, apesar do disposto no artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei 8.072/90, o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena. É incabível o estabelecimento de regime mais favorável ou a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, até pelo disposto na lei mencionada, que exige tratamento mais rigoroso para o delito aqui tratado, e dos motivos esposados na primeira fase.

Por fim, a despeito das alterações promovidas pela Lei 12.736/12 no art. 387, do Código de Processo Penal, especialmente a inclusão da regra trazida no § 2º deste último dispositivo (o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade), deixo de aplicar de forma antecipada a detração penal por entender que esta lei modificadora é materialmente inconstitucional, afrontando os princípios da individualização da pena, do juiz

natural e da isonomia (art. 5º, da Constituição Federal). A propósito, cabe trazer a lume os ensinamentos do Prof. César Dário Mariano da Silva em recente artigo publicado na revista eletrônica Consultor Jurídico:

“O princípio da individualização da pena está previsto no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, e dispõe que caberá à lei regular a individualização da pena.

A individualização da pena desenvolve-se em três etapas: a legislativa, a judicial e a executória.

(...)

A nova lei fundiu em uma etapa a judiciária e a de execução das penas, uma vez que, ao proferir sentença, poderá o Juiz promover de regime o condenado sem atentar para a análise do seu mérito, de acordo com o previsto no artigo 112 da Lei de Execuções Penais, que dispõe: “A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão”

Com efeito, a Lei das Execuções Penais, que é especial, contém normas que devem ser observadas para a correta individualização da pena. O condenado deverá cumprir a pena privativa de liberdade em etapas cada vez menos rigorosas até obter a liberdade, devendo, para tanto, ser observado seu mérito. Sem essa análise do merecimento para a progressão de regime, inclusive com a realização do exame criminológico quando necessário, está sendo violado o disposto no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal, que dispõe sobre a individualização da pena.

A Lei a ser observada por ocasião da progressão de regime é a das Execuções Penais, que é especial e traz os requisitos necessários, que devem ser analisados pelo Juiz Natural da causa, que é o das Execuções Penais e não o prolator da sentença.

Destarte, somente com o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 112 da Lei das Execuções Penais é que poderá ser deferida a progressão de regime pelo Juiz das Execuções Criminais, observado o princípio do juiz natural (art. 5º, LIII, CF), a teor do disposto no artigo 66, inciso III, alínea “b”, da Lei das Execuções Penais.

E se não bastassem esses argumentos, haverá situações em que pessoas condenadas exatamente às mesmas penas e pelos mesmos crimes terão tratamento totalmente diferente em situações iguais, com evidente violação ao princípio da isonomia.

Assim, v.g, aquela pessoa condenada à pena privativa de liberdade e que tenha sido presa provisoriamente terá abatido o período pelo próprio Juiz da Condenação para fins de progressão, podendo ser diretamente promovida de regime sem a observância do mérito; ao passo que o condenado, que não tenha cumprido prisão provisória, deverá obter a progressão com o preenchimento dos requisitos do artigo 112 da Lei das Execuções Penais a serem analisados pelo Juiz das Execuções Criminais. Há, portanto, dois pesos e duas medidas, ou seja, pessoas sendo tratadas de forma totalmente diferente em situações iguais, violando, assim, o princípio constitucional da isonomia (art. 5º, “caput”, da CF)”(<http://www.conjur.com.br/2012-dez-10/cesar-dario-lei-tornar-automatica-progressao-regime> - acesso em 17.12.2012, às 00h40min)

Ressalte-se: a modificação proposta pelo legislador é capaz de gerar odiosa injustiça, na medida em que os condenados que tenham sido submetidos a custódia cautelar durante o processo (justamente porque a sua liberdade colocava em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal

- art. 312, do Código de Processo Penal) seriam beneficiados em detrimento daqueles que puderam responder ao processo em liberdade, provavelmente indivíduos menos perigosos para a sociedade.

E não é só. A antecipação da detração penal acarreta a supressão, no caso de réus presos cautelarmente, das regras para progressão de regime de cumprimento de pena privativa de liberdade, o que também se reflete em insustentável atentado ao princípio da isonomia.

Tudo isso sem considerar a possibilidade de que o réu esteja preso em razão de prisão preventiva decretada em vários processos, quando a aplicação irrestrita do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal poderá acarretar a consideração do mesmo período de prisão cautelar para fins de detração em várias sentenças condenatórias, o que não se pode admitir.

Assim sendo, por entender que o art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal viola a disciplina constitucional, deixo de aplicá-lo, o que faço com arrimo no controle de constitucionalidade difuso.

Carlos Pereira dos Santos

Na primeira fase, atentando ao disposto no art. 42 da Lei 11.343/06, observo que a pena-base deve ser majorada, considerando a alta potencialidade lesiva do entorpecente apreendido ("crack"), substância altamente nociva e viciante. Verifico, ainda, que o réu ostenta maus antecedentes pela prática de crime idêntico ao ora processado (Proc. 0007068-51.2012.8.26.0302 - fls. 95/96), pelo que fixo sua pena-base acima do mínimo legal em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa.

Na segunda fase, aponto a agravante da reincidência, que é específica (fls. 94/95 - Proc. 0000363-17.2015.8.26.0598). Assim, majoro a reprimenda para 7 anos e 6 meses de reclusão e 750 dias-multa.

Na terceira fase, a reincidência do réu e os seus maus antecedentes ensejam o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06.

Assim, a reprimenda acima fixada torna-se definitiva, à mingua de outras causas de aumento ou de diminuição.

Considerando a reincidência, os maus antecedentes e os motivos esposados na primeira fase, a pena deverá ser cumprida inicialmente no regime fechado, nos termos do art. 33, CP.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia para CONDENAR, pela prática do crime tipificado no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/2006, o réu EDUARDO DOS SANTOS CONCEIÇÃO SOUZA, vulgo "Arroz", à pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 194 dias-multa, no mínimo legal, e CARLOS PEREIRA DOS SANTOS, vulgo "Cal", qualificados nos autos, à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 750 dias-multa, no mínimo legal, mas para ABSOLVÊ-LOS da prática do delito previsto no artigo 35, "caput", da Lei 11.343/2006, com fulcro no artigo 386, VII, CPP.

Considerando a pena e regime aplicado ao réu Eduardo, sua primariedade e o fato de que Carlos responde ao processo em liberdade por ordem do E. Superior Tribunal de Justiça, faculto, excepcionalmente, o mesmo benefício em relação ao acusado Eduardo. Expeça-se, pois, alvará de soltura clausulado e comunique-se ao E. Tribunal de Justiça.

Nos termos do artigo 63 da Lei 11.343/06, declaro o perdimento dos objetos, importe pecuniário e motocicleta apreendidos.

Custas ex lege.

Oportunamente, expeça-se o necessário e archive-se.

P.I.C.

Jaú, 03 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA